

1524647-48.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Augusto Ramos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... do entorpecente era, indubitavelmente, o tráfico e o consumo de terceiros.

Nesse diapasão: "para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524647-48.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524647-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Augusto Ramos

Vistos.

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS e RÔMULO DANILO SANTOS SENA, qualificados, respectivamente, às fls. 10 e 13, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de outubro de 2021, às 15:15 horas, na Rua Helvetia, 44, Santa Cecília, nesta Capital, agindo com unidade de propósitos e desígnios, traziam consigo meio "tijolo" de maconha, com peso total de 195,5 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, destinada ao fornecimento para terceiras pessoas.

Recebida a denúncia (fls. 132/133), os acusados foram devidamente citados (fls. 148 e 150). Foi apresentada resposta escrita à acusação (fls. 157/161), sendo mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação comuns à defesa, sendo os réus interrogados ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia e a defesa, por sua vez, requereu a absolvição, formulando pedidos subsidiários em caso de condenação.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada face ao auto de flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05) auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 32/34), laudo químico-toxicológico (fls. 172/174), laudo pericial na balança encontrada (fls. 136/138), bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

O guarda municipal Edson Mikalkenas disse em Juízo que estava na região da cracolândia. Aduziu que por meio de monitoramento de câmeras de vigilância, foi verificada uma movimentação de venda de drogas. Disse que durante a triagem e limpeza do local, o monitoramento passou via rádio quem estava traficando no local do fluxo. Abordou um e o parceiro abordou o outro réu. Afirmou que abordou o réu Romulo. Com ele havia um tijolo de maconha. Disse que Romulo passou a droga para Felipe, por isso Romulo estava sem droga no momento da abordagem. A droga estava com o Felipe.

O guarda municipal Leonardo Luiz Vercelino, em Juízo, deu versão semelhante.

Em seu interrogatório judicial, o réu Felipe disse que é morador de rua e usuário de crack. Disse que pegou uma sacolinha preta para ganhar um grama de crack. Iria levar a sacolinha para o interior do fluxo da cracolândia. Não pretende falar de quem recebeu a sacolinha. Conhece Romulo da cracolândia. Nunca conversou, nem fumou com ele. Fazia 3 ou 4 meses que vivia na cracolândia. Sua família é do interior de São Paulo.

Em seu interrogatório judicial, o réu Rômulo disse que é da Bahia e fazia uso de drogas na cracolândia. Um rapaz perguntou se queria vender para ganhar algum dinheiro e drogas. Receberia 60 reais e maconha em troca. Estava há cerca de duas semanas na cracolândia. Conhecia Felipe de vista da região. Não passou o tijolo para Felipe. Foi preso antes de Felipe. Estava vendendo drogas e não repassou qualquer droga para Felipe. A droga que estava vendendo ficou lá no local.

Observo que basta a adequação da conduta a algum dos tipos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas para a configuração do crime de tráfico. Assim, basta a conduta de trazer consigo, como no caso dos autos, para a sua perfeita consumação (crime de mera conduta), aliadas as demais circunstâncias do fato.

Trata-se, ainda, de delito de perigo abstrato, pois representa a probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para sua consumação, não se permitindo ao infrator a prova de que seu comportamento era inofensivo (Guilherme de Souza Nucci, Lei Penais e Processuais Comentadas, 5ª edição, Ed. RT, 2010, pág. 356/356, nota 46 ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Diante de todos os elementos de prova que foram colhidos ao longo da instrução criminal, incontestemente que os acusados traziam consigo as drogas encontradas pelos policiais, sendo que as confissões dos réus, ainda que parciais, foram corroboradas nos autos.

Os guardas municipais foram uníssonos ao narrarem que durante monitoramento das câmaras municipais da região conhecida como "cracolândia", puderam perceber o indiciado Rômulo comercializando entorpecentes, agindo como chefe de uma "banca" de drogas no local dos fatos, interagindo com diversas pessoas e, aparentemente, entregando e recebendo objetos (imagens de fls. 39/65).

Ato contínuo, perceberam que Rômulo entregou determinada quantidade de entorpecente e uma balança de precisão a Felipe, o qual, portando um cobertor do desenho animado "Ben 10", deixava o local, por ocasião da limpeza periódica. Assim, os guardas deliberaram pela abordagem dos indivíduos, em que encontraram com Rômulo a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e com Felipe a droga apreendida, bem como uma balança de precisão, recebida de Rômulo instantes antes.

Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos guardas ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, pois nada há nos autos a indicar que tentaram prejudicar o réu ou que teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra ele.

Também o fato de serem guardas, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. Releva notar, ainda, por importante, que o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.

Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar de guardas municipais.

No mais, a quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, a quantia em dinheiro encontrada, bem como a balança apreendida, tudo isso aliado ao depoimento harmônico dos guardas, bem como dos laudos juntados aos autos, permite-se concluir, com absoluta certeza, que a destinação do entorpecente era, indubitavelmente, o tráfico e o consumo de terceiros. Nesse diapasão: "para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (artigo 52)" (Lei de Drogas Comentada, Luiz Flávio Gomes, p. 182).

Não é o caso, assim, de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que a quantidade apreendida em poder dos acusados e as demais provas que demonstram a prática do tráfico.

Assim, a autoria é indubitosa conforme amplamente visto acima, devendo os réus serem condenados pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo à individualização da pena.

Quanto ao réu Felipe, a pena base do crime de tráfico deve ser fixada acima do mínimo legal, em atenção ao disposto tanto no artigo 42 da Lei de Drogas, quanto no artigo 59 do Código Penal. Verifico da certidão de objeto e pé (fls. 78/81) e folha de antecedentes (fls.70/75) que o réu possui maus antecedentes, tendo sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, nos autos do processo nº 0000004-35.2015.8.26.0447 da Vara de Pinhalzinho-SP; e nos autos do processo nº 0000890-39.2012.8.26.0447 da Vara de Pinhalzinho-SP. Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo que a pena-base deve ser aumentada em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente específico em tráfico de drogas (certidão de objeto e pé certidão de objeto e pé de fls. 78/81 e folha de antecedentes de fls.70/75), possuindo condenação anterior, com trânsito em julgado, distinta das consideradas na primeira fase de dosimetria, nos autos do processo nº 0000830-95.2014.8.26.0447 da Vara de Pinhalzinho-SP. De outro lado, o réu confessou os fatos, motivo pelo qual entendo ser o caso de compensar a agravante com atenuante, mantendo a pena da primeira fase.

Na última fase não existem causas de aumento ou diminuição de pena. Anoto que a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser aplicada, pois o acusado é reincidente específico em crime doloso, além de possuir maus antecedentes, conforme visto nas fases anteriores. Portanto, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, sendo inviável fixação de regime mais brando, em razão da pena aplicada e da reincidência do acusado conforme previsão expressa do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e natureza do delito cometido.

Incabível, ainda, a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo temporal (04 anos) previsto no artigo 44, inciso I do Código Penal, bem como pela reincidência (artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Por fim, considerando que o réu respondeu ao processo em prisão cautelar, bem como por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública a aplicação da lei penal, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Observo, apenas, que o tráfico de entorpecentes é crime legalmente classificado como hediondo, de modo que possui gravidade diferenciada, sendo que os indivíduos que se propõem à sua prática são considerados presumivelmente perigosos. Libertar os que deste tipo de crime se beneficiam equivaleria a incentivar a sua prática, cuja expansão tem causado grande dano à comunidade, desestruturando famílias bem formadas e gerando aumento de violência.

Quanto ao réu Rômulo, na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto tanto no artigo 42 da Lei de Drogas, quanto no artigo 59 do Código Penal, não observo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (conforme folha de antecedentes de fls. 76/77 e certidão de objeto e pé de fls. 82/83), motivo pelo qual fixo a pena base do crime de tráfico no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo. Não há outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, entendo que deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, não ostenta maus antecedentes criminais (conforme folha de antecedentes de fls. 76/77 e certidão de objeto e pé de fls. 82/83), e nem integra qualquer organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. Ademais, a quantidade de drogas apreendida não possui expressividade suficiente para causar menor redução de pena, motivo pelo qual entendo que a redução deve ser realizada no patamar de 3/5, próximo ao máximo, resultando na pena final de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicada e a primariedade do acusado.

Finalmente, o acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois presentes todos os requisitos expressos no artigo 44 e incisos do Código Penal.

E, além do réu ser primário, entendo que a medida é socialmente recomendável (artigo 44, § 3º do Código Penal), tendo em vista que o acusado não se envolveu em delitos semelhantes depois do fato dos autos, nem há prova neste sentido. Quanto à possibilidade de substituição no crime de tráfico, o E. Supremo Tribunal Federal tem decidido pela sua possibilidade:

“Habeas Corpus. Constitucional e penal. Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Possibilidade. A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ de 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ de 12.12.10. Ordem concedida” (HC 102.678, Relator Ministro Eros Grau).

Com este entendimento, enfim, prestigia-se o princípio constitucional da individualização da pena. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal): 1) prestação pecuniária na quantia equivalente a um salário-mínimo, a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais; 2) prestação de serviços à comunidade, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

O réu poderá recorrer em liberdade para este processo, pois incompatível a prisão cautelar com o regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e:

a) CONDENO o acusado FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo cada dia multa fixado em 1/30 do salário-mínimo, no piso legal, devendo ser cumprida em regime inicial fechado.

O réu FELIPE não poderá apelar em liberdade, nos termos da fundamentação acima.

b) CONDENO o acusado RÔMULO DANILO SANTOS SENA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo, devendo ser cumprida em regime inicial aberto.

Nos termos da fundamentação acima, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação pecuniária na quantia equivalente a um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções e (2) prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da privativa de liberdade.

O réu RÔMULO poderá apelar em liberdade, nos termos da fundamentação acima. Expeça-se alvará de soltura com relação ao réu RÔMULO.

Oportunamente, lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA